



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 177/15
ביחד עם 210/15

בענין: סלים עבוד

התובע/
הנתבע שכנגד

ע"י ב"כ עו"ד שמעון רביב
דרך העצמאות 5, חיפה
טל: 04-8671112, פקס: 04-8641066

נ ג ז

1. יעקב חביב
יעקב קטרין

הנתבעים

ע"י ב"כ עו"ד מוראד ביקי
מרח' ביאליק 3, חיפה 33112
טל: 04-8628810, פקס: 04-8628812

2. חלווה אסעד
חלווה נמרה

הנתבעים/
התובעים שכנגד

ע"י ב"כ עו"ד גסאן חורי
רח' הבנקים 4, חיפה ת.ד. 33143
טל: 04-8507760, פקס: 04-8507740

פ ס ק - ז י נ

1. עניינה של התביעה בקשה למתן צו עשה אשר יחייב את הנתבעים להרוס בניה בלתי חוקית שבנו בחצר המשותפת של הבית ללא הסכמות יתר בעלי הדירות בבית ולחייבם להשיב את המצב לקדמותו.

2. הבית מושא ההליך נמצא ברח' אחז 8, חיפה, מזוהה כחלקה 60 בגוש 10825 ומכיל 6 דירות. חלקת משנה מס' 1 בבעלות נתבעים מס' 1 (להלן: "יעקב"); נתבעים מס' 2 (להלן: "חלווה") זכאים להירשם כבעלים של חלקות משנה מס' 2 ו-3, והתובע הוא הבעלים של חלקת משנה מס' 5 (להלן: "עבוד"). דירות הנתבעים מצויות בקומת הקרקע של הבית. בעורף דירות אלו קיימת חצר המהווה רכוש משותף. נטען כי נתבעים מס' 1 בנו בחצר הבית מבנה בו הם מחזיקים בחזקה ייחודית, ונטען כי נתבעים מס' 2 יצקו משטח בטון בחצר אותו ריצפו, הקימו מעליו פרגולה ורעפים, בנו מדרגות יציאה לחצר ובנו חדר על משטח הבטון, באופן הגורם הפרעה לתובע.

3. חלווה הגישו כנגד עבוד תביעה שכנגד בה עתרו לחייב את עבוד לאפשר להם עשיית שימוש במחסן המהווה רכוש משותף, והמצוי מתחת למדרגות בבית, בו תפס לטענתם עבוד חזקה ייחודית (להלן: "התא").

4. עבוד טען להגנתו כי מדובר בתא ששטחו אינו עולה על 1 מ"ר. תא זה הוקם ע"י הבעלים שקדם לו לשימושו הפרטי בהסכמת כל בעלי הדירות בבית, הראיה ששלוש שנים עבוד עושה בו שימוש ייחודי ללא מחאה מצד מי מבעלי הדירות בבית.

להלן תמצית טענות ההגנה של יעקב בתביעה העיקרית:

5. הבניה המתוארת בכתב התביעה מתייחסת למחסן משותף שנבנה לפני שנים רבות על פי היתר בנייה. בשנת 1988, עת רכשו יעקב את דירתם הם ביצעו שיפוצים באותו המחסן בהסכמת כל בעלי הדירות שגרו באותו מועד בבית. היות ויתר בעלי הדירות בבית לא היו מוכנים להשתתף בעלויות שיפוץ המחסן המשותף הוסכם כי יעקב ישפצו אותו על חשבונם ויעשו בו שימוש ייחודי. הדבר נעשה בהסכמת כל מי שהיו בעלי דירות בבית באותו המועד.

6. מאז ומעולם מחובר המחסן למים ולחשמל בדירת יעקב.

7. בשנת 2007 שיפצו יעקב בשנית את המחסן ואף גידרו את השטח הסמוך לו. הואיל והגידור חרג לשטח החלקה הסמוכה הוגש כתב אישום כנגד יעקב.

8. התובע רכש דירתו בשנת 2010 בידעו כי יעקב מחזיקים במחסן בחזקה ייחודית.

9. אין להיעתר לתביעה מהטעם שעבוד בעצמו תפס חזקה ייחודית בשטח משותף מתחת למדרגות, וכן סגר מרפסת פתוחה. למצער, יש לראות בעבוד כמי שביצע "הרחבה דומה" כאמור בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

להלן תמצית טענות ההגנה של חלווה בתביעה העיקרית:

10. היות והמצב הנוכחי קיים מזה שנים רבות וטרם שעבוד רכש את דירתו הרי שחלה על התביעה התיישנות ולחילופין, חל שיהוי.

11. חלווה רכשו בשנת 2011 את דירותיהם במצב כפי שהוא היום ולא בנו או השתלטו על רכוש משותף. חלווה ביצעו תיקונים בגג קיים במרפסת אשר אינם טעונים היתר ואין בהם הפרעה למאן דהו.

ההליכים בתיק-

12. ביום 13.10.15 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

(א) בין הבית לבין גבולה הצפון-מזרחי של החלקה קיים מעבר המוביל אל החצר המשותפת המצויה בעורף הבית. השביל נחסם בסופו על ידי מבנה עם דלת הקיים בפינה הצפונית של החלקה. במפתח לדלת מבנה זה אווזים יעקב.

(ב) המבנה הנ"ל הוא מבנה נפרד בן קומה אחת בשטח לא מבוטל אשר בנוי מחלל גדול אחד ומותקן בו מטבח. נראה כי הוא נועד לשמש כמחסן גדול או כיחידה נפרדת (להלן: "המחסן"). מצדו הדרומי של המחסן קיימת כניסה/יציאה נוספת המובילה אל יתר חצר הבית.

(ג) היות והגישה לחצר מכיוון צפון-מזרח נחסמה ע"י המחסן שבנו יעקב האפשרות היחידה להגיע לחצר האחורית היא ע"י איגוף הבית מדרום.

(ד) הופניתי אל הגדר הבנויה בגבולה המזרחי שבין החלקה לבין החלקה הסמוכה לה. נטען כי תוואי הגדר הוסט ע"י יעקב.

(ה) בעורף דירת חלווה קיימת מרפסת בנויה עם מעקה המוגבהת מפני הקרקע בכ- 50 ס"מ. 4 מדרגות מובילות ממרפסת זו אל החצר (להלן: "המרפסת"). בחצר, בהמשכה של מרפסת זו קיים משטח בטון נוסף שאינו מרוצף (להלן: "משטח הבטון").

(ו) המרפסת ומשטח הבטון מקורים באמצעות גג גלי שמעליו החלה התקנת רעפים (להלן: "הגג"). מעל גג זה מצויה מרפסת דירת עבוד.

13. ביום 17.11.15 וביום 27.1.16 התקיימו דיוני הוכחות בתיק במהלכם העידו מטעם התביעה/ההגנה שכנגד: מר פרל אוסקר, גב' סאוסן סאבא, בעלים של דירות נוספות בבית, מר אלכס צביבק, מפקח במחלקת הפיקוח על הבניה בעיריית חיפה, ומר אליאס עבוד, בנו של התובע (בפרוטוקול נרשם בטעות כי העיד סלים עבוד. בפועל מי שהעיד הוא בנו אליאס עבוד). מטעם ההגנה/תביעה שכנגד העידו: מר יעקב חביב ומר חלווה אסעד, הנתבעים בתיק.

14. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב בהם חזרו על עיקרי טענותיהם לעיל וכעת כל שנתר לי הוא להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

15. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה וכן את התביעה שכנגד ולהורות על סילוק ידם של חלווה של אסעד ושל עבוד מהרכוש המשותף. הכול כפי שיפורט להלן.

המחסן-

16. בלשכת רישום המקרקעין המחסן אינו רשום בבעלות מי מבעלי הדירות בבית ומשכך הוא מהווה רכוש משותף. הצדדים להליך לא טענו ולו פעם אחת כי המחסן אינו מהווה רכוש משותף.

17. בכתב האישום שהוגש בשנת 2011 בת.פ. 355/11 כנגד יעקב (הוגש וסומן ת/3) מפורטות עבודות הבניה שביצעו יעקב כדלקמן: "בחזית הצפון מערבית מתחת לסככה בלתי חוקית קיימת בחצר, בנו קירות עם ציפוי אבן עם חלונות ודלתות והכשירו שטח של כ- 63 מ"ר למגורים ע"י בניית תקרה דקורטיבית, מטבח, תאורה ועבודות אינסטלציה. יצוין כי חלק מהמבנה פולש לחלקה ציבורית שכנה (חלקה 58)". יעקב הודו בעובדות כתב האישום, הורשעו בעבירה שיוחסה להם ובגזר הדין בתיק חויבו בין היתר: "הנני מצווה על הנאשמים להרוס את הבניה שנבנתה שלא כדין, כמתואר בכתב האישום. הנאשמים יבצעו את ההריסה עד ליום 15.6.14 אלא אם עד לאותו יום יקבלו הנאשמים היתר בניה כחוק."

18. ענינו הרואות כי בפן התכנוני אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי המחסן נעדר היתר בנייה כדין.

19. כבר מהטעם שיעקב הודה בעובדות כתב האישום אין לקבל את טענתו כיום ולפיה במועד בו רכש את הנכס היה קיים במקום מחסן אשר נבנה בהיתר.

20. זאת ועוד, אמנם בתוכניות הישנות של הבית, לרבות תוכנית היתר הבניה משנת 1946 (הוגש וסומן נ/3), משורטט מלבן במיקום בו כיום בנוי המחסן, אך אינני מקבלת את טענת יעקב כי סימון זה מעיד על קיומו של מחסן הבנוי בהיתר. ראשית, על גבי המלבן המסומן מופיע הכיתוב "cistern" אשר תרגומו הוא: "בור, מקוה מים, בריכה, מיכל מים, גב, דות, ביר, גת", ומכאן שאין להסיק ממנו על קיום מחסן בנוי כפי שמנסה יעקב לטעון. שנית, מעדותו של מר צביבק עלה כי אותו מלבן שסומן בתוכנית היתר הבניה לא נכלל בבקשה להיתר הבניה, ומשכך היתר הבניה לא התייחס אליו, אלא התוכנית ביקשה להדגים קיומו של המסומן בשטח, בבחינת מצב קיים, ראו עדותו בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 24-29. שלישית, מעדותו של מר צביבק בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 32-34 ובעמ' 8 שורות 1-9 עלה כי בחומר המצוי בתיק הבניין קיים תיעוד בכתב לכך שבשנת 2007 הייתה קיימת במקום רק סככה פתוחה, הכוללת גג ועמודי פלדה, ולכך שבמהלך השנים לאחר מכן ועד למועד המשפט השני בשנת 2011 ביצע יעקב עבודות בניה והפך את הסככה בהדרגה למחסן. תיעוד זה מתיק הבניין עומד בסתירה לטענת יעקב כי המחסן היה קיים מקדמת דנא וכי התקבל לגביו היתר בניה.

21. לאור האמור מוצאת אני לקבוע כי מחומר הראיות שבא לפני שוכנעתי כי המחסן הוסף במהלך השנים על ידי יעקב על גבי רכוש משותף, וכי לא ניתן היתר לבנייתו. למעלה מהדרוש, אציין כי אפילו הייתי מקבלת את הטענה כי המחסן נבנה על פי היתר אזי לא הוכח שהבעלות באותו מבנה הוקנתה ליעקב ושארין המדובר במבנה המהווה רכוש משותף.
22. באשר לטענת ההתיישנות, דינה להידחות. כבר נקבע בפסיקה כי הסגת גבול במקרקעין הינה עוולה מתמשכת, במובן זה שעילת התביעה מתחדשת מיום ליום, ולפיכך אינה מתיישנת (ראו בעניין זה ע"א 35/71 חב' ישראל אוסטרליה בע"מ נ' מושב בני דרור בע"מ, פד"י כז' (1) 228 והפסיקה המצוטטת שם וכן ע"א 831/80 זמיר נ' כימיקלים ופוספטים בע"מ פ"ד לז' (3) 122).
23. אשר לטענת השיהוי, מעדותו של מר אליאס עבוד עלה כי בניית המחסן נמשכה ב"אופן זוחל". לטענתו, עת רכשו הוריו את הדירה כבר היו התחלות בנייה במקום, אך עדיין הייתה קיימת גישה חופשית לחצר המשותפת. לטענתו, הוא מחה באוזני יעקב מספר פעמים על מעשיו ואף הגיש מספר תלונות לעיריית חיפה, ראו עדותו בעמ' 16 שורות 5-22 ובעמ' 18 שורות 32-33. עדותו של העד הייתה אמינה עלי ותאמה לעדויות יתר עדי התביעה ולחומר הראיות שהוגש לתיק. מקום בו עבוד פנו ליעקב ולעירייה בתלונות כנגד הבניה לא ניתן לטעון כנגדם כי השתהו.
24. האם ניתנה הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית לבניה?
25. יעקב טענו כי קיבלו את הסכמתם של כל בעלי הדירות שהיו בבית במועד בו ביצעו את עבודות הבניה/השיפוץ, ומשכך, עבוד אשר רכש את דירתו בשלב מאוחר יותר מחויב לאותן הסכמות שנתנו הבעלים הקודמים בדירתו ואינו יכול להתכחש להן.
26. בהקשר לכך העיד יעקב כי רכש את דירתו בשנת 1987, וכי היה קיים במקום מחסן רעוע שהיה בשימוש ייחודי של הדירה אותה רכש. לטענתו, בסמוך למועד הרכישה קיבל את "ברכת הדרך" מכל בעלי הדירות בבית לשפץ את המחסן על חשבונו ולעשות בו כראות עיניו, ואכן, לטענתו, שיפץ אותו ועשה בו שימוש עד שנת 2007. בשנת 2007 היות והתקרה דלפה והיו סדקים בקירות המחסן שיפצו בשנית, ראו עדותו בעמ' 23 שורות 3-20.
27. מצאתי להעדיף את גרסת יתר העדים ממנה עלה שיעקב הוא זה שבנה את המחסן על פני גרסתו של יעקב ולפיה המחסן היה קיים ערב הרכישה והוא רק שיפץ אותו. מעדויות כל עדי התביעה עלה כי מדובר בבניה שבוצעה ע"י יעקב. מר אוסקר תיאר בעדותו כיצד בנה יעקב את המחסן שלב אחרי שלב החל מהמועד בו נכנס לגור בבית, למורת רוחו, וכיצד איים עליו לבל יגיע למקום, ראו עדותו בעמ' 1 לפרוטוקול שורות 20-15 ובעמ' 2 שורות 18-1. העד העיד כי הגיש מס' פעמים תלונות על הבניה לעירייה.

28. על אף גילו המתקדם של העד (לדבריו קרוב ל-90) ניכר כי העד היטיב לתאר את השתלשלות העניינים בבית לפרטי פרטים, לרבות ציון שמות בעלי הדירות הקודמים בבית. ניכר כי זכרוננו מצוין ועדותו הייתה אמינה עלי.

29. הגב' סאסא העידה כי בשנת 1995 עת רכשה את דירתה, לא היה קיים במקום המחסן, וכי החל משנת 2001 או בסמוך לכך החל לאט לאט יעקב משתלט על הרכוש המשותף, בנה סככה סגר אותה והפכה למחסן עד לגודלו הנוכחי בשטח של כ-63 מ"ר, ראו עדותה בעמ' 11 שורות 22-6 שאף היא הייתה אמינה עלי.

30. עדויות אלו עולות בקנה אחד עם הודאתו של יעקב בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום, ת/3, שם צוין באופן מפורש כי "בתקופה בין אוגוסט 2007 לבין יולי 2010, ביצעו הנאשמים עבודות בניה" ובהמשך - "הנאשמים הינם אחראים לעבודות הבניה המפורטות לעיל". הודאת יעקב בעובדות אלו תומכת בעדויות יתר עדי התביעה, ומוצאת אני לדחות את עדות יעקב כיום כי רכשו את הבית עם מחסן קיים.

31. מחומר הראיות שבא לפני התרשמתי כי עבוד לא שקטו על השמרים ואף הגישו תלונות לעירייה בנוגע לבניית המחסן. לדידי גם אין לקבל את טענת יעקב כי עבוד מחויבים להסכמות שנתנו קודמיהם ליעקב לעשות שימוש ייחודי במחסן. בין מהטעם שהסכמות שכאלו לא הוכחו. ובין מהטעם שהסכמות כאלו אפילו ניתנו אין בהם כדי ויתור קנייני המחייב את עבוד, אלא לכל היותר יש לראות בהם הסכמות אישיות המחייבות את נותניהם בלבד. זאת ועוד, אפילו הייתי מקבלת את טענת יעקב כי קודמיהם של עבוד לא התנגדו לעבודות שביצעו יעקב במקום גם בכך אין בכך כדי להוות הבטחה או ויתור על זכות קניינית, ובוודאי שאין בכך כדי לחייב את חליפיהם, וראו לעניין זה הדברים שנאמרו בע"א (ת"א) 271/85 הילמן נ' רוזן, פ"מ תשמ"ז (1) 283:

"מקובל שדיירי הקומות העליונות בבתים משותפים נמנעים מלאכוף בפועל את זכותם הקניינית בחצר הבית ומתירים לדיירי קומת הקרקע להשתמש בשטח הצמוד לדירתם בין בדרך של הקמת גינה או לצרכי ישיבה ושהייה וכיוצא בזה, אולם לדעתי אין להסיק מהתנהגות כזו מסקנות של הבטחה או ויתור על זכויותיהם. אם ננהג בדרך זו נאלץ את בעלי הדירות הגבוהות להפגין התנגדות ואי שביעות רצון, כדי למנוע בעתיד טענות של מניעות ע"י התנהגות או הבטחה."

32. טרם סיום פרק זה אציין כי אמנם יעקב הגיש, עפ"י הנטען, בקשה ללגליזציה לגבי המחסן אך כפי הידוע מתן היתר בניה מכשיר את הבנוי אך ורק בפן התכנוני ואינו מהווה הכשר בפן הקנייני. זאת ועוד, כבר נקבע בפסיקה כי בניית מחסן כגון דא לנוכח היותו נפרד מדירת יעקב אינו מהווה הרחבת דירה, ראו בעניין זה את רע"א 1462/10 עטייה נ' שגיא (פורסם בנבו), משכך, מדובר על תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף לה נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. וראו בעניין זה את סעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") ואת הדברים שנאמרו בספרו של המלומד ויסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף (1997), עמ' 454-455.

33. משנקבע כי בניית מחסן בנפרד מהבית אינה מהווה "הרחבת דירה" ממילא לא יכול לחול על בנייה זו סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין שעניינו "הרחבה דומה", לא כל שכן מקום בו לא הוכח כי ניתן היתר בניה למחסן זה.

34. לאחר שמצאתי כי יעקב הוא שבנה את המחסן וכי לא נתונה לו הסכמת כל בעלי הדירות בבית, מוצאת אני להורות לו להרוס את המחסן ולפנות את פסולת ההריסות מהחצר. ההריסה והפינוי יסתיימו לא יאוחר מיום 30.12.16. לוח הזמנים שנקבע להריסה הוא בשים לב לעובדה שהריסת מבנה קיים טעונה אף היא היתר בניה שבאחריות יעקב להשיגו.

המרפסת, משטח הבטון והגג-

35. בתוכנית הבקשה להיתר בניה שהוגשה וסומנה נ/3 ובתוכנית הבית המשותף שהוגשה וסומנה נ/4 מודגמת מרפסת בדירת חלווה. גם בכל התמונות שהוגשו לתיק קיימת מרפסת לדירה זו. הצדדים לא הגישו חוות דעת מודד או אסמכתאות אחרות המעידות מהו שטח המרפסת הקיים אל מול שטח המרפסת המודגם בהיתר הבניה. משכך, מוצאת אני לקבוע שלא הוכח כי המרפסת אינה חוקית או כי נבנתה או הוגדלה ע"י חלווה לאחר מועד מתן היתר הבניה, ולא מצאתי לתת סעד בעניינה

36. באשר לבניית משטח הבטון והגג מעל המרפסת, ככל שימצא כי הללו נעשו ע"י חלווה הרי שיהיה נכון להחיל לגביהם את הוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין הקובע כי לשם ביצוע שינויים או תיקונים ברכוש המשותף נדרשת תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית.

37. בהתאם להלכה שנקבעה בע"א 163/63 **לוינהים נגד שוורצמן** פ"ד י"ז, (3) 1722 ושלא שונתה עד היום, אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

38. חלווה העיד כי מעולם לא יצק, לא בנה דבר בחצר וגם לא הביא אחרים לעשות זאת, וזו עדותו בעניין: "נשבע בהן צדק, אני לא יודע לא מגדר לא מבון, לא ממדרגות לא משום דבר. כלום. הידיים האלה לא יצקו לא בטון ולא הבאתי מי שיצק בטון. לא יצקתי שום בטון..". ראו עדותו בעמ' 29 לפרוטוקול שורות 33-37. בהמשך עדותו סותר העד את עדותו הקודמת, ועת נשאל האם ביקש היתר בניה לגג שעשה השיב: "הבנאדם שעבד אצלי אמר לי שהכל חוקי. אמרתי לו בסדר." (ראו באותו עמ' בשורה 17). עדותו של חלווה גם עמדה בסתירה לעדות יתר העדים בתיק, לרבות לעדותו של מר צביבק, מפקח במחלקה לפיקוח על הבניה בעיריית חיפה, המוחזק על ידי כעד ניטראלי שאין לו כל עניין אישי בתיק, ואשר תפורט להלן.

39. מצאתי להעדיף את עדות יתר העדים שנשמעו בפניי על פני עדותו של חלווה. להלן יפורטו העדויות בהתייחס לגג ולמשטח הבטון:

40. מר אוסקר העיד כי חלווה בנו את הגג מעל המרפסת והחצר, ראו עדותו בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 26-30. מר אוסקר העיד כי טרם שחלווה רכשו את הדירה אמנם הייתה קיימת יציאה מהדירה לחצר, אך לא הייתה קיימת סככה ולא היה קיים משטח בטון. ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 20-32.
41. מר צביבק העיד כי הפרגולה ביציאה מדירת חלווה נבנתה בחודש דצמבר 2014 ע"י חלווה. מעדותו עלה כי בעקבות תלונה שהוגשה הוא ביקר במקום ביום 3.12.14 ולא מצא עקבות לבנייה, אך בביקור חוזר שלו במקום ביום 8.12.14 הגג כבר היה בנוי, ראו עדותו בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 30-32. העד אף הדגיש בעדותו כי בביקור הראשון לא היה קיים גג ואף לא סככה, ראו בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 30-37. עדות זו מפריכה את טענת חלווה כי במועד בו רכש את הדירה כבר היה בנוי גג מעל המרפסת.
42. הגב' סאבא העידה אף היא כי עד לבואם של חלווה לגור בבית מעולם לא הייתה קיימת פרגולה/גג מעל המרפסת. לטענתה, חלווה התחילו לבנות את הפרגולה בסוף שנת 2014. בתמיכה לאמור הגישה העדה תמונה, סומנה ת/9 (לטענתה התמונה צולמה בחודש אוגוסט 2014), כפי שניתן לראות בבירור בתמונה לא קיימת סככה או גג מעל המרפסת ומעל משטח הבטון, וראו עדותה בעמ' 11 שורות 35-40 וכן בעמ' 15 שורות 8-9.
43. עוד העידה העדה שהבעלים שקדמו לחלווה יצקו משטח בטון בחצר אך מידותיו אינן זכורות לה.
44. העד מר עבוד העיד כי בדצמבר 2014 בנו חלווה את הגג המודגם בתמונה ת/14, ויצקו משטח בטון גדול במקום בו היה קיים משטח בטון קטן. לטענתו, משטח הבטון שהיה קיים עבר בקו ישר עם המדרגה האחרונה וכל משטח הבטון הקיים מהמדרגות ואילך הוסף על ידי חלווה, ראו עדותו בעמ' 17 לפרוטוקול שורות 20-23.
45. בין המוצגים שהוגשו לתיק הוגשה תמונה נ/10, אשר לא ברור מהו המועד בו צולמה, וממנה עולה כי במועד בו צולמה משטח הבטון לא היה קיים וגם לא היה קיים קירוי למרפסת דירת חלווה.
46. מר יעקב העיד כי הייתה קיימת כבר בשנות ה-90 סככה עם אסבסט מעל מרפסת דירת חלווה, וכי כשחלווה רכש את דירתו הסיר את הסככה ובנה תחתיה פרגולה, ראו עדותו בעמ' 25 שורות 17-20. במקום אחר העיד העד כי גגון האסבסט הוצא לפני שחלווה נכנס לגור, ראו עדותו בעמ' 28 שורות 16-18. בהיות עדויות העד סותרות מוצאת אני את עדות העד בלתי אמינה. זאת ועוד, עדותו ולפיה חלף סככת האסבסט נבנתה הסככה הנוכחית גם היא אינה עולה בקנה אחד עם התמונה שהוצגה לי (סומנה ת/9) בה רואים בבירור כי לא היה קיים קירוי/גג מעל המרפסת.

47. לסיכום האמור מוצאת אני לקבוע כי שוכנעתי שחלווה הם אלו שבנו את הגג מעל המרפסת. משלא הוכיחו כי קבלו את הסכמת האסיפה הכללית לבניית הגג, לא מלכתחילה ואף לא בדיעבד, מוצאת אני להורות על פירוקו.

48. חלווה יפרקו את הגג לא יאוחר מיום 10.5.16 ויפנו על חשבונם את מה שיפורק.

49. באשר למשטח הבטון, מעדות עדי התביעה, אשר פורטו לעיל, עלה כי היה קיים בחצר משטח בטון טרם שרכשו חלווה את הדירה. אמנם מחומר הראיות עלה בבירור כי חלווה הגדילו את משטח הבטון, אך לא הוכח לי מה היה גודלו של משטח הבטון טרם שהוגדל וכפועל יוצא מה שיעור ההגדלה. משכך, אינני מוצאת לחייב את חלווה להרוס על חשבונם את משטח הבטון.

50. יחד עם זאת, ומאחר ומדובר על משטח שנוצק ברכוש המשותף, בו אין לחלווה כל זכויות קנייניות, מורה אני כי אסיפת בעלי הדירות בבית ברוב קולות תהא רשאית להחליט בנוגע לדינו של משטח זה. ככל שיוחלט על פירוקו ייעשה הדבר על ידי נציגות הבית המשותף במימון כל בעלי הדירות בבית כחלק מ"תחזוקת הרכוש המשותף", ככל שלא תתקבל החלטה המורה על הריסתו יוותר המשטח על כנו וישמש כרכוש משותף לכל בעלי הדירות בבית.

התא-

51. מדובר על שטח המצוי מתחת לגרם המדרגות המשותף, ואין חולק כי הוא מהווה רכוש משותף. בשלב כלשהו – שמועדו המדויק לא הוכח – נסגר חלל זה והפך לתא המהווה אף הוא רכוש משותף.

52. לעניין התא העיד מר אוסקר כי במועד בו נסגר היה המפתח לתא נתון בידי כל בעלי הדירות בבית, ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 29-34.

53. הגב' סאסא העידה כי ויתרה על זכותה לעשיית שימוש בתא לטובת משי' זהאר, מי שמכרו את הדירה לעבוד, ראו עדותה בעמ' 12 שורות 3-8.

54. יעקב העיד כי התא היה בחזקה משותפת של עבוד ושל חלווה, וכי יום בהיר אחד החליפו עבוד את מפתח התא ומאז הם שוללים שימוש מחלווה, ראו עדותו בעמ' 25 לפרוטוקול שורות 1-5. לטענתו הוא לא התבקש וממילא לא נתן הסכמה לעבוד לעשיית שימוש בתא, וראו גם עדותו בעמ' 28 שורות 1-3.

55. מר עבוד העיד שכאשר רכשו הוריו את הדירה הוא עבר בין כל בעלי הדירות בבית, ביקש וקיבל את הסכמתם לעשיית שימוש בתא, לרבות ממי שהיו באותו המועד הבעלים בדירת חלווה. לטענתו חלווה בעצמם מעולם לא הלינו על השימוש שעושים עבוד בתא ותלונה זו באה לעולם רק בעקבות התביעה שהוגשה כנגדם. העד הסכים כי תא זה מהווה רכוש משותף, אלא שלטענתו קיבל מפתחות לו ממי שרכש ממנו את הדירה, חלווה לא דרשו לעשות שימוש באותו תא וכיום

מפאת חוסר אמון שקיים בין הצדדים לא ניתן לעשות בו שימוש משותף, ראו עדותו בעמ' 20 שורות 18-29.

56. חלווה העיד כי מי שמכר לו את הדירה הבהיר לו כי קיימת לו זכות שימוש בתא, אלא שעבוד לא נתנו לו מפתח, ראו עדותו בעמ' 29 שורות 20-25, וכן בעמ' 30 שורות 31-36.

57. מה היא משמעותה של אותה רשות שנתנו בעלי הדירות בבית לעבוד לעשות שימוש בתא?

58. פרופ' נ. זלצמן הגדירה במאמרה "רשיון במקרקעין", הפרקליט מ"ב [1995], בעמ' 24, את הרשיון במקרקעין כך:

"רשיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין... לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס... ואפשר שתינתן על ידי בעל המקרקעין, ללא כוונה ליצור התחייבות חוזרת כאקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס..."

עוד קובעת פרופ' זלצמן בעמ' 57-63 למאמרה הנ"ל כי:

"בגדר המושג רשות מכללל נכללים כל אותם מצבים שבהם החזקה או השימוש של פלוני אינם מעוגנים בהסכמה מפורשת שנתן בעל המקרקעין, אלא בהסכמה הנלמדת ממחדלו של בעל המקרקעין לפעול לסילוקו של פלוני מן הנכס... ההסכמה נלמדת ממשך הזמן שחלף ומהתנהגותו הפסיבית של בעל המקרקעין, בנסיבות המקרה, המעידה שהשלים עם נוכחותו של פלוני בנכס או עם השימוש שהוא עושה בנכס. ההסכמה הנלמדת משתיקתו של בעל המקרקעין מטהרת את החזקה או השימוש מיסוד אי החוקיות שדבק בו והופכת את מעשה העוולה למעשה ברשות".

וראו גם ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד ל"א(3) 214,210 שם נקבע כי:

"לצורך היווצרותו של רשיון במקרקעין, די בהתנהגותם של בעלי המקרקעין. ממנה ניתן להסיק, שהסכימו בדיעבד לשימושם של אחר ברכושם והשלימו עמו, ואין צורך בהסכם מפורש".

על דברים דומים חזרו גם בע"א 463/79 ג'בארן נ' ג'בראן, פ"ד ל"ו(4), 403, 438.

59. מחומר הראיות עלה כי ככל שניתנה לעבוד או לקודמיהם רשות לעשיית שימוש בתא הרי שמדובר על רשום חינוס. בפסיקה נקבע כי רשות חינוס ניתנת לביטול בכל רגע, וראו בעניין זה את ע"א 96/50 צינקי נ' כיאט, פ"ד ה(1), 474 שם נקבע:

"רשיון הניתן חינוס, ללא כל תמורה, איננו הסכם במובן החוקי של המילה. רשיון כזה מתפרנס מדי רגע ברגע מרצונו החופשי של המרשה והוא מתבטל כהרף עין עם גילוי דעתו של זה, כי אין ברצונו להמשיך בהענקת הרשיון".

60. במאמרה של פרופ' נ' זלצמן **"רשיון במקרקעין"**, הפרקליט מב' חוברת א' (תשנ"ה), 24 נאמרו דברים דומים לעניין ביטולה של רשות חינוך וכך נאמר שם:

"רשיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס. "רשות במקרקעין" באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם החזקה ושימוש בנכס, או שימוש בלבד.... הרשות נעדרת כוונת הקנייה של זכות בנכס. אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין... ואפשר שתנתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס. רשות גרידא באה להבחין איפוא מן הרשות החוזית. תוכנה של הרשות החוזית, משך קיומה ותנאי סיומה ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים. רשות גרידא אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנותנו רשאי לבטלו בכל רגע..." (הדגשה שלי י.ל.)

61. בדומה לכללי המניעות האחרים, ההשתק הקנייני מבוסס על הציפיה שיצר בעל המקרקעין בהתנהגותו אצל בר הרשות, כאשר בר הרשות שינה את מצבו לרעה על בסיס התנהגות זו. לעניין הציפיה כתבה פרופ' זלצמן במאמרה כי:

"הפעלתו של ההשתק מותנית בהתקיימותן של נסיבות מיוחדות המעידות על הציפיה שיצר בעל המקרקעין אצל פלוני, בהסכמה מפורשת או בשתיקה, בדבר זכותו להחזיק או להשתמש בנכס ועל הסתמכותו של פלוני ושינוי מצבו לרעה כתוצאה מכך "נ' זלצמן "רשיון במקרקעין", שם, 30)

62. ובמקום אחר בדונה בהשתק הקנייני או הרשות מכוח ההשתק כתבה פרופ' זלצמן:

"הסתמכותו של מקבל הרשות על הציפיה שיצר אצלו בעל המקרקעין ושינוי מצבו לרעה, ישפיעו על המשך קיומם של יחסי הרשות ויכולת סיומם באורח חד צדדי על ידי בעל המקרקעין". (נ' זלצמן "רשיון במקרקעין", עמ' 42)

63. בנסיבות תיק זה לא מצאתי לקבוע כי עבוד הסתמכו על הרשות לעשיית שימוש בתא באופן ששינו מצבם לרעה, ולפיכך חלווה רשאים לדרוש לעשות שימוש אף הם בתא.

64. לאור האמור, ומשמצאתי כי מדובר בשטח המהווה רכוש משותף בו קיימים זכויות לכל בעלי הדירות, מורה אני לאסיפה הכללית של הבית להחליט האם ייעשה בתא שימוש במשותף של כל בעלי הדירות בבית או האם התא ייועד למחסן אשר ישמש לחומרי ניקיון וכיוב' של הנציגות. ככל שלא תתקבל החלטה של האסיפה הכללית בעניין בתוך 30 יום מהיום יעביר עבוד העתק המפתח לתא לכל בעל דירה יהיה מעוניין בעשיית שימוש בתא ואשר ידרוש ממנו קבלת מפתח בכתב.

הגדר-

65. מחומר הראיות עלה כי תוואי הגדר בין החלקה לחלקה הסמוכה לה מכיוון צפון-מערב הוסט. בכל התוכניות שהוגשו מופיעה בעורף הבית גדר אשר עוברת באופן אלכסוני, ראו נ/ו-4. בתמונות שהוגשו וכן מהביקור במקום שנערך עלה כי הגדר הקיימת עוברת בצורת מדרגה, ראו תמונות ת/15.
66. לטענת עבוד חלווה ויעקב אחראים במשותף להסטת הגדר, ראו עדותו בעמ' 19 לפרוטוקול שורות 24-35.
67. חלווה הכחיש כל קשר לגדר שהוסטה אך לעומתו יעקב הודה במיוחס. ראו עדותו של יעקב בעמ' 24 לפרוטוקול שורות 9-6 שם הוא מודה כי העתיק את מיקום הגדר ופלש לשטח הציבורי. לטענתו בעקבות דרישת העיריה החזיר את הגדר למקומה, ראו גם עדותו בעמ' 26 שורות 2-3.
68. אמנם יעקב טען כי הגדר כבר הוחזרה למקום אך לא הובאו כל ראיות לתמוך בנטען. לאור האמור מורה אני ליעקב להחזיר את הגדר לתוואי המופיע בתוכניות נ/ו-4 וזאת בהתאם לתוכנית מודד שיקבל. ביצוע האמור ייעשה על ידי יעקב ועל חשבונו לא יאוחר מיום 10.5.16.

סוף דבר-

69. אני מורה ליעקב להרוס את המחסן ולהעתיק את תוואי הגדר כמפורט בסעיפים 34 ו-68 לעיל.
70. אני מורה לחלווה להרוס את הגג כמפורט בסעיף 47-48 לעיל.
71. אני מורה לעבוד ביחס לתא כמפורט בסעיף 64 לעיל.
72. אני מחייבת את יעקב לשלם לעבוד הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 6,000 ₪ ומחייבת את חלווה לשלם לעבוד הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מהיום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה [6.5.15] ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כח' באדר א' התשע"ו (8.3.16).

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין